

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제2절 소송요건>

I. 승소판결을 받기 위한 요건

1. 소장의 적식심사

- 소장의 적식심사란 원고가 제출한 소장이 법률이 정한 형식적 요건을 갖추었는지를 심사하는 단계이다. 재판장은 소장에 당사자, 법정대리인, 청구 취지, 청구원인이 제대로 기재되어 있는지, 정해진 인지가 첨부되었는지를 확인한다. 기재사항에 흠결이 있거나 인지가 부족한 경우 재판장은 상당한 기간을 정하여 보정을 명하며, 원고가 이에 응하지 않을 시 소장각하명령을 내린다. 이는 본안 심리에 들어가기 위한 가장 기초적인 형식적 관문이다.

2. 소의 적법심사

- 소의 적법심사란 소송요건을 구비하였는지를 판단하는 절차이다. 소송요건은 법원이 본안 판결(승소 또는 패소 판결)을 내리기 위해 필요한 전제 조건이다. 관할권의 존재, 당사자능력 및 당사자적격, 소의 이익 등이 여기에 해당한다. 만약, 소송요건이 결여되어 있고 그것이 보정될 수 없는 것이라면 법원은 본안에 대한 판단 없이 소장각하판결을 내린다.

3. 주장 자체의 정당성

- 주장 자체의 정당성이란 원고가 주장하는 사실이 모두 진실이라고 가정했을 때, 법률적으로 원고가 원하는 승소 판결을 얻을 수 있는 상태인지를 의미한다. 이를 청구의 이유 있음이라고도 한다. 원고가 주장하는 사실관계가 법령상의 요건을 충족하지 못하거나, 원고가 주장하는 법률효과가 인정되지 않는 경우에는 증거조사를 할 필요도 없이 청구기각판결을 받게 된다.

4. 주장사실의 증명

- 원고가 주장한 사실이 법률적으로 정당하더라도, 피고가 그 사실을 다투는 경우에는 원고가 그 사실의 존재를 증명하여야 한다. 법관이 원고의 주장 사실이 진실하다는 확신을 갖게 하는 증거력을 확보하는 단계이다. 만약, 원고가 증거를 통해 요건사실을 증명하지 못하면 진위불명의 상태가 되어 증명 책임의 원칙에 따라 원고는 패소의 불이익을 입게 된다.

II. 소송요건

1. 소송요건의 의의

- 소송요건이란 법원이 사건의 본안에 대하여 심리하고 판결하기 위하여 필요한 전제 조건을 말한다. 소송요건은 당사자가 임의로 배제할 수 없는 강행규정적 성격을 지니며, 이는 국가 재판권의 적정한 행사를 보장하고 부적법한 소송으로부터 피고와 법원을 보호하기 위한 장치이다.

2. 소송요건의 종류

(1) 법원에 관한 것

- 대한민국의 재판권이 존재하여야 하며, 당해 사건에 대한 관할권이 있어야 한다. 또한 법관에게 제척·기피 사유가 없어야 한다.

(2) 당사자에 관한 것

- 당사자가 실재하여야 하며, 당사자능력, 소송능력, 정당한 당사자적격이 있어야 한다. 법정대리인이 필요한 경우에는 대리권의 흠결이 없어야 한다.

(3) 소송물에 관한 것

- 소의 이익(권리보호의 이익)이 존재하여야 하며, 확정판결이 있는 사건과 동일한 사건이 아니어야 한다(기판력의 저촉 금지). 또한 중복제소에 해당하지 않아야 한다.

(4) 특수소송에 관한 것

- 행정소송에서의 전심절차 이행이나, 가사소송에서의 조정전치주의 등 특별법상 요구되는 전제 조건들이 이에 해당한다.

3. 소송요건의 모습

(1) 적극적 요건과 소극적 요건

- 적극적 요건은 재판을 받기 위해 존재하여야 하는 요건(관할권, 당사자능력 등)이며, 소극적 요건은 재판을 받기 위해 존재하지 않아야 하는 요건(법관의 제척·기피 사유, 중복제소, 기판력의 저촉 등)을 의미한다.

(2) 직권조사사항과 항변사항

- 직권조사사항은 당사자의 주장 여부와 관계없이 법원이 스스로 조사하여야 하는 사항이며 소송요건의 대부분이 이에 해당한다. 반면, 항변사항은 피고가 관할 위반의 항변이나 중재 합의의 존재 등을 주장하여야만 비로소 법원이 고려하는 사항이다.

4. 소송요건의 조사

(1) 직권조사사항에 대한 조사

- 법원은 소송의 어느 단계에서나 직권으로 소송요건의 존부를 조사할 수 있다. 상고심에서도 새로운 증거를 통해 소송요건의 흠결을 판단할 수 있으며, 당사자가 다투지 않더라도 법원이 인지한 경우 반드시 판단하여야 한다.

(2) 항변사항에 대한 조사

- 임의관할 위반이나 소송비용 담보제공 신청 등은 피고가 본안에 관하여 변론하기 전까지 이의를 제기하여야 조사 대상이 된다. 피고가 이의 없이 변론하면 관할권 등이 확정되는 변론관할의 효과가 발생한다.

5. 소송요건의 증명

(1) 증명방법

- 소송요건의 존부에 관한 사실은 본안에 관한 사실과 달리 엄격한 증명을 요하지 않으며 자유로운 증명으로 족하다. 법원은 공문서나 당사자의 진술 등을 통해 소송요건의 유무를 판단할 수 있다.

(2) 증명책임

- 적극적 요건의 존재에 대해서는 원칙적으로 소를 제기한 원고가 증명책임을 진다. 반면, 기판력이나 중복제소와 같은 소극적 요건의 존재에 대해서는 이를 주장하며 소의 부적법을 다투는 피고가 증명책임을 진다.

(3) 존재의 판단시기

- 소송요건의 존부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 판단한다. 소 제기 당시에는 흠결이 있었더라도 변론종결 시까지 구비되었다면 적법한 소가 된다. 반대로 소 제기 시에는 구비되었으나 그 후 상실되었다면 부적법한 소가 된다.

6. 조사의 순서

(1) 문제점

- 여러 개의 소송요건이 문제될 때 어떤 순서로 심리하여야 하는지가 문제된다.

(2) 학설

- 특정한 순서가 있다는 견해와 법원의 자유로운 선택에 맡겨야 한다는 견해가 대립한다. 다만, 재판권의 존재나 당사자 실재 여부 등 근본적 요건은 우선 심리되어야 함에 이견이 없다.

(3) 판례(소송요건심리의 선순위성 인정)

- 판례는 소송요건은 본안 심리에 앞서 판단되어야 한다는 선순위성을 강조한다. 소송요건이 구비되지 않은 경우에는 본안에 관한 심리를 진행해서는 안 된다는 것이 확고한 태도이다.

(4) 검토

- 불필요한 본안 심리를 방지하고 소송 경제를 도모하기 위해 명백한 소송요건 흠결이 있는 경우 이를 우선적으로 판단하여 소를 종결시키는 것이 타당하다.

7. 조사 후 법원의 조치

(1) 소송요건이 구비된 경우

- 법원은 본안 심리로 나아가 청구의 당부를 판단한다.

(2) 소송요건에 흠이 있는 경우

- 보정이 가능한 경우(예 : 대리권 흠결) 법원은 보정을 명하여야 한다. 보정이 불가능하거나 기간 내에 보정되지 않으면 판결로써 소를 각하한다.

(3) 흠결을 간과한 판결

- 소송요건 흠결을 간과하고 내린 본안 판결은 상소 사유가 된다. 다만, 당사자능력 흠결(사자상대)과 같은 중대한 하자가 아닌 한 판결이 확정되면 기판력이 발생하며 당연무효라고 보기는 어렵다.

(4) 소송요건이 구비되었음에도 소각하판결을 한 경우

- 원고는 상소를 통해 구제를 받을 수 있다. 상소심 법원은 소각하판결이 부당하다고 인정하면 원심판결을 취소하고 사건을 원심법원으로 환송하여 본안 심리를 하게 하여야 한다.

Ⅲ. 결론

- 승소 판결을 얻기 위한 과정은 형식적 소장 심사에서 시작하여 소송요건의 적법 심사를 거쳐 본안의 실질적 정당성과 증명에 이르는 단계적 구조를 가진다. 소송요건은 법원이 본안에 대한 판단을 내리기 위한 문턱으로서, 공정한 재판의 전제 조건이자 절차적 정의의 핵심이다. 법원은 소송요건을 엄격히 심사하여 부적법한 소송을 걸러내야 하지만, 동시에 보정 기회를 충분히 부여함으로써 국민의 재판받을 권리가 형식적인 이유로 박탈되지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다. 본안 심리와 소송요건 심리의 조화로운 운용은 민사소송의 이상인 적정·평등·신속·경제의 실현을 위한 기초가 된다 할 것이다.